

1501782-95.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... tem conhecimento do envolvimento dele com o tráfico. Conhece a testemunha Alexandro e já ouviu comentários de que estaria envolvido com o tráfico (v. mídia). A testemunha Aparecida, arrolada pela Defesa, disse ser conhecida do réu e da genitora dele. Afirmou que toda vez que passava na frente da casa dele o via lá sentado, e não tem nada mal para falar dele, desconhecendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501782-95.2021.8.26.0530

Controle: 2021/001654

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210220/2021 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DOMINGOS ZANDONI

Réu Preso

Aos 16 dias do mês de dezembro de 2021, às 13:00 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS: o Promotor de Justiça, Dr. EDUARDO LUIZ MICHELAN CAMPANA; o réu Gustavo Domingos Zandoni, sua Defensora constituída, Dra. MAYARA BALBINOT (OAB/SP 353701) e a testemunha arrolada pela Defesa Alexandro da Silva Teixeira; COMPARECERAM presencialmente no prédio do fórum desta comarca: as testemunhas arroladas em comum Policiais Militares Martin Monteiro de Castro Souza e Diego José Sichieri e as testemunhas arroladas pela Defesa Raissa de Oliveira Silva, Kaique Nonato Brandão e Aparecida Luciana Barroso Moreira. AUSENTES: as testemunhas arroladas pela Defesa Joilson Marques e Franklin Wesley dos Santos Garcia. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas em comum Policiais Militares Martin Monteiro de Castro Souza e Diego José Sichieri e as testemunhas arroladas pela Defesa Alexandro da Silva Teixeira, Raissa de Oliveira Silva e Aparecida Luciana Barroso Moreira, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no

sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. Pela Dra. Defensora foi dito que DESISTE da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa Joilson Marques, Franklin Wesley dos Santos Garcia e Kaique Nonato Brandão, o que foi homologado. A seguir o MM. Juiz interrogou o réu Gustavo Domingos Zandoni, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: Vistos.

GUSTAVO DOMINGOS ZANDONI, vulgo "Bruxo" qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 19h50min, na Rua Expedicionário Solano nº 3146, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, trazia consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 1 (um) "tijolo" de Crack pesando 1.041,75g (um quilo, quarenta e um gramas e setenta e cinco decigramas), substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina no local supracitado quando avistaram um veículo Citroën/C3, placas EN04D14, e decidiram abordá-lo. Ao notar a aproximação da viatura, seus ocupantes empreenderam fuga e foram perseguidos pelos policiais, os quais presenciaram o instante em que o passageiro do automóvel arremessou pela janela um pacote posteriormente apreendido e identificado como sendo um "tijolo" de Crack. Em seguida, a trajetória do carro foi interceptada e os indivíduos foram identificados como sendo Alexandro da Silva Teixeira, motorista do veículo, e o réu Gustavo, que ocupava o banco do passageiro. No interior do automóvel, foram apreendidos dois telefones celulares e a quantia de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais).

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 110/112). O réu foi citado (fls. 116) e apresentou defesa prévia (fls. 134/137).

Durante a instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como foram ouvidas seis testemunhas arroladas pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal.

A Defesa requereu a absolvição do réu, por negativa de autoria e insuficiência de provas, alegando, em síntese, que foi o motorista Alexandro quem fugiu da polícia, o qual apresentou versões diversas para os fatos e ainda possui diversas passagens criminais, bem como conhecido como traficante, tendo sido o réu, em realidade, traído pela testemunha Alexandro. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de penas mínimas e regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04 e 21), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pela imagem fotográfica (fls. 23), pelo exame químico-toxicológico (fls. 88/90), conclusivo por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também está comprovada. Vejamos a prova colhida.

As testemunhas policiais militares Martin e Diego , na fase policial, narraram que durante patrulhamento, na data e local dos fatos, avistaram um veículo Citroën/C3 de placa EN04D14 ocupado por dois indivíduos suspeitos, decidindo por abordá-los. Narraram que os ocupantes de tal automóvel, ao perceber a aproximação policial, partiram em fuga com o veículo e, realizada imediata perseguição pelos PMS, estes avistaram o passageiro do automóvel jogar um pacote pela janela, tentando se livrar de algo. Segundo as testemunhas, logo em seguida conseguiram abordar o veículo, identificando os seus ocupantes como Alexandro (testemunha/ motorista) e Gustavo (réu/passageiro). No veículo foram apreendidos 02 (dois) aparelhos de telefone celular e a quantia de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais). Os depoentes afirmaram que conseguiram recuperar o pacote que o passageiro Gustavo havia jogado ao solo pela janela do veículo, constatando se tratar de 01 (um) "tijolo" de Crack pesando cerca de 1.041,75 g (um quilo, quarenta e um gramas e setenta e cinco decigramas.). Os policiais afirmaram ainda que ao inquirir os abordados, Gustavo se calou, porém, o motorista Alexandro afirmou que Gustavo havia retirado o pacote das vestes e jogado pela janela do veículo. Alexandro esclareceu ainda às testemunhas que era amigo de Gustavo e este lhe havia solicitado uma carona do município de Ribeirão Preto/SP até esta cidade de Sertãozinho/SP, onde ocorreu a abordagem policial. Segundo as testemunhas, Alexandro disse que não tinha conhecimento que Gustavo detinha em sua posse (em meio às vestes) o material entorpecente, porém presenciou o momento em que ele retirou tal "pacote" de suas vestes e jogou pela janela do automóvel, durante a perseguição policial. Disse que somente após a abordagem policial tomou conhecimento que o pacote que Gustavo havia jogado pela janela do veículo se tratava de substância entorpecente. Alegou que se evadiu dos policiais por solicitação de Gustavo e, que naquele momento o apavorou. Por fim, os depoentes afirmaram que Alexandro disse ter conhecimento que Gustavo já havia sido preso anteriormente pelo delito de tráfico de drogas (fls. 15/16 e 17).

Em Juízo, os policiais confirmaram que após visualizarem dois indivíduos dentro de um veículo, que esboçaram nervosismo ao verem a aproximação da viatura, resolveram abordá-los, mas não obedeceram a ordem de parada. Segundo o policial Diego, o motorista chegou a se abaixar, tentando se esconder, ao ver a viatura. Durante o acompanhamento, viram com segurança que o passageiro arremessou algo para fora do veículo, inclusive por ter colocado o braço inteiro para fora do veículo, segundo confirmou o policial Diego. Tal objeto arremessado foi posteriormente localizado e apreendido pelo policial Diego, e constatado tratar-se de um tijolo de crack, cujo quilo vale de R\$ 20.000,00 a R\$ 25.000,00. Após abordado o veículo, o réu Gustavo disse que estava apenas pegando uma carona com Alexandro, de um sítio até a casa dele, pois são vizinhos, bem como nada disse quando indagado a respeito do entorpecente encontrado. Já Alexandre disse que dava uma carona para Gustavo de Ribeirão Preto a Sertãozinho, por morarem próximos, e que também o viu retirando algo da bermuda e dispensado do veículo. Também disse que empreendeu fuga por receio de ter seu veículo apreendido e que não tinha conhecimento que o réu trazia droga consigo, e também a pedido de Gustavo, segundo disse o policial Diego. Por fim, disseram que os réus são conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico, e Alexandro também pela prática de outros delitos. Confirmaram que também prenderam Alexandro com droga cerca de 2 semanas depois. O policial Diego recordou-se que a genitora de Gustavo compareceu na Delegacia de Polícia durante a apresentação da ocorrência, dizendo que Alexandro esteve em sua residência naquele dia e chamou Gustavo para fazerem algo (v. mídia).

A testemunha Alexandro, na fase policial, disse que é amigo do réu e que ele havia solicitado uma carona do município de Ribeirão Preto/SP até esta cidade de Sertãozinho/SP, onde ocorreu a abordagem policial. Durante o percurso, Gustavo retirou um pacote das vestes e o jogou pela janela do veículo. Não tinha conhecimento que Gustavo detinha em sua posse o material entorpecente, mas presenciou o momento em que o acusado retirou tal "pacote" de suas vestes e jogou pela janela do automóvel, durante a perseguição policial. Disse que somente após a abordagem policial tomou conhecimento que o pacote que Gustavo havia jogado pela janela do veículo se tratava de substância entorpecente. Esclareceu que se evadiu dos policiais por solicitação de Gustavo, e que naquele momento ficou apavorado.

Disse ter conhecimento que Gustavo já havia sido preso anteriormente pelo delito de tráfico de drogas (fls. 18).

Em Juízo, a testemunha Alexandro disse que após chegar do trabalho, na data dos fatos, foi chamado por Gustavo para irem numa adega, onde encontraram duas amigas, Vitória e Carol. Também deu carona para Carol até Ribeirão Preto. Quando estava em Ribeirão Preto, Vitória ligou para Carol pedindo para que o depoente desse carona para Gustavo. Após pegar Gustavo, numa chácara, foram abordados por policiais, mas tentou fugir porque os pneus do carro estavam careca. Disse que anteriormente já tinha sido abordado pelas testemunhas policiais, que constataram que o pneu estava careca, mas foi liberado após se comprometer a trocar os pneus; naquela ocasião os policiais também disseram que bateriam nele caso o encontrasse sem que os pneus tenham sido trocados. Durante a abordagem os policiais apenas encontraram um baseado que o depoente e o réu estavam usando. Somente após reconhecerem Gustavo como egresso é que os policiais resolveram levá-los para a Delegacia. Não sabe o motivo pelo qual Gustavo foi preso. Os policiais chegaram a pedir ao depoente para que dissesse ter visto o réu jogar algo para fora do veículo. Porém, nega ter falado essa versão na Delegacia. O advogado Dr. Eliezer somente chegou na Delegacia após ter prestado depoimento. Gustavo usava roupa de "futebol" não ocasião e não trazia nenhum volume em suas vestes. Dias após foi preso injustamente pelas testemunhas policiais, acusado da prática do tráfico, mas foi absolvido (v. mídia). A testemunha Raissa, arrolada pela Defesa, disse ser amiga do réu e que o conhece desde criança, sendo uma pessoa "tranquila" e sempre a ajudou. Sabe que o réu já trabalhou fazendo bico de servente de pedreiro com o marido da declarante. Frequenta muito a residência do réu e não tem conhecimento do envolvimento dele com o tráfico. Conhece a testemunha Alexandro e já ouviu comentários de que estaria envolvido com o tráfico (v. mídia).

A testemunha Aparecida, arrolada pela Defesa, disse ser conhecida do réu e da genitora dele. Afirmou que toda vez que passava na frente da casa dele o via lá sentado, e não tem nada mal para falar dele, desconhecendo envolvimento do réu com o tráfico. Também nunca viu o réu praticar o tráfico, mas apenas comentários (v. mídia).

O réu Gustavo, interrogado na fase policial, narrou que estava em uma chácara e ligou para Alexandro para pedir uma carona. Durante o percurso de volta para a sua casa, estava fumando um baseado juntamente com Alexandro quando este disse "o que é aquilo atrás de nós?". Nesse momento olhou para trás e viu um vulto em sua janela pela qual Alexandro arremessou algo. Disse que "eu não vi o que ele (Alexandro) jogou pela minha janela eu pensei que era o baseado, pois a gente já tava chapado". Finalizou dizendo que depois os policiais militares os abordaram e apresentaram um quilo de Crack dizendo que era dos ocupantes do veículo (fls. 19). Em Juízo, negou a acusação. Alega que chegou do serviço por volta de 17 horas. Após tomarem um banho, chamou Alexandro, seu vizinho, para irem até a Adega. Neste local encontraram Vitória e Carol. Em certo momento Alexandro deu carona para Carol até Ribeirão Preto, enquanto o interrogando levou Vitória para a casa dela. Após isso, pediu para Alexandro que o buscasse. Depois que Alexandro o buscou, os policiais deram ordem para que parasse, quando então foi reconhecido pelos policiais como recém egresso. Viu apenas Alexandro jogar algo pela janela, acredito ser o baseado pela janela. Não viu os policiais encontrar a droga apreendida (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização, ainda que não tenha sido flagrado negociando a venda do entorpecente com qualquer pessoa.

A apreensão do entorpecente foi possível porque os policiais avistaram o veículo supracitado, com dois indivíduos em seu interior, e que apresentaram comportamento suspeito pois ficaram nervosos ao verem a viatura, motivo pelo qual decidiram pela abordagem, mas não respeitaram a ordem de parada, saindo em fuga.

Durante o acompanhamento, confirmaram que viram o passageiro do veículo, no caso o

réu, jogar um pacote pela janela, o qual foi posteriormente apreendido e constatado pelos policiais como sendo um "tijolo" de Crack, informação já confirmada pelo laudo pericial de fls. 88/90. O material foi descrito como contendo Cocaína, pesando 1.041,75g (um quilo, quarenta e um gramas e setenta e cinco decigramas). Após bem sucedido alcance dos ocupantes do carro em fuga, os policiais disseram que a eles foi relatado pela testemunha Alexandro que Gustavo havia retirado o pacote das vestes e jogado pela janela do veículo, ao ver a aproximação policial. Ademais, Alexandro reafirmou esse relato quando ouvido na Delegacia de Polícia. Em todos os três depoimentos, é certa a informação de que o material foi arremessado pela janela do passageiro, sendo que este local estava ocupado pelo réu. O policial Diego, não bastasse, com riqueza de detalhes, disse em Juízo que chegou a ver que o braço do passageiro, identificado como sendo o réu, foi visto inteiramente do lado de fora do carro, indicando que não ser possível que tenha sido o motorista a pessoa responsável por dispensar a droga.

Tal relato de Alexandro, prestado na fase policial, ademais, não pode ser desprezado, notadamente por ser coerente e compatível com as demais provas produzidas nos autos.

Não bastasse, caberia à Defesa demonstrar que o depoimento prestado perante a autoridade policial foi obtido por meio ilícito, porque ser presumível que a autoridade policial age no estrito cumprimento do dever legal.

Por sua vez, não é crível a alegação de Alexandro, ou mesmo a do réu, de que os policiais tenham forjado o flagrante, ou que os policiais estivessem transportando um tijolo de crack de valor estimado entre R\$ 20.000,00 a R\$ 25.000,00, e tenham levado o réu Gustavo na Delegacia, assim como a testemunha Alexandro, apenas porque reconheceram Gustavo como recém egresso e porque a testemunha Alexandro não trocou os pneus carecas de seu veículo.

E ainda que o réu tenha sido traído pela testemunha Alexandro, conforme sustentou a Defesa em alegações finais, dando a entender que o real proprietário da droga seria apenas Alexandro, ficou bem comprovado nos autos que foi o réu quem dispensou a droga, segundo firmes depoimentos dos policiais. Ou seja, tinha o réu conhecimento da existência da droga e no mínimo auxiliou Alexandro no transporte e tentativa de ocultação da droga, de modo que evidentemente deve ser responsabilizado pelo delito de tráfico.

Ademais, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais ou de guardas municipais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Coeso testemunho dos policiais militares - Validade – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Tráfico caracterizado – Condenação mantida – PENA – redutor no patamar máximo – necessidade – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 – Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves – d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP – Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 – Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira – d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA ORAL INCRIMINADORA – A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP – APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 – Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib – d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Assim, considerando a significativa quantidade de droga apreendida (1.041,75g (um quilo, quarenta e um gramas e setenta e cinco decigramas, constituindo um "tijolo" de Crack), permite-se concluir que não se destinaria apenas para seu uso próprio, pois apreendida quantidade muito superior àquela normalmente encontrada com meros usuários, mas sim a consumo de terceiros.

Não bastasse, o réu já foi condenado anteriormente pela prática do mesmo delito (v. certidão de fls. 37/38 – autos nº 1501733-88.2020.8.26.0530) indicando que continua praticando o tráfico, ainda que para complementar sua renda.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência

probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, diante da natureza da droga que o réu transportava, o "crack", que tem efeito devastador à saúde e potencial de causar rápida dependência.

Quanto à agravante sustentada pelo Ministério Público em alegações finais, prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, reputo que não incide no caso, por considerar que a pandemia do coronavírus não causou situação de calamidade pública, ainda que formalmente assim decretada por decretos, mas apenas restrições do tráfego de parte da população, e impedimento, também somente em certo período, do exercício de algumas atividades profissionais. Também não há prova de que os delitos teriam sido cometidos aproveitando-se o acusado da situação de pandemia, ou em razão dela, nem houve descoberta de elementos colhidos durante a instrução processual nesse sentido.

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa. Porém, no presente caso, foi apreendida grande quantidade de droga (1 "tijolo" de crack pesando 1.041,75g), que além de indicativa de profissionalização na conduta, representa um perigo maior à saúde pública, por atingir inúmeros usuários, de forma que sua conduta evidentemente implica alto risco à sociedade.

A quantidade encontrada também indica que o réu possui forte e duradoura ligação com o narcotráfico, pois caso contrário, não lhes seria confiada tão valiosa mercadoria.

O réu ainda já foi condenado por delito semelhante nos autos de nº 1501733-88.2020.8.26.0530, conforme certidão de fls. 37/38, tendo referida condenação inclusive já sido mantida em segunda instância, conforme consulta feita nesta data, mas ainda sem trânsito em julgado, indicando que continua praticando o tráfico, ainda que para complementar sua renda.

E segundo os policiais, o réu já era conhecido nos meios policiais como traficante, indicando que claramente se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo, que tem se dedicado frequentemente à traficância, notadamente porque não comprovado nos autos, com segurança, o exercício de qualquer atividade remunerada lícita por parte do réu.

Por todos referidos motivos, o réu não pode ser considerado mero traficante eventual ou se sustentar que não se dedica a atividades criminosas.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a

única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, ressalto que o réu transportava relevante quantidade de droga, a tratar-se de crack, que tem efeito devastador à saúde e potencial de causar rápida dependência, já foi condenado pela prática de delito semelhante, a indicar que realmente vivia desta atividade ilícita, a merecer ser duramente apenado.

E também pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GUSTAVO DOMINGOS ZANDONI, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pelo Réu e sua Dra. Defensora e pelo Promotor de Justiça foi dito que irão se manifestar dentro do prazo. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Aguarde-se eventual interposição de recurso por parte da Defesa e do Ministério Público. Após tornem os autos conclusos para deliberações. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.